

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

Alameda João Vieira Simões, 135, Fórum Desembargador Gregório Magno, Muquiçaba, GUARAPARI - ES - CEP: 29214-110
Telefone: (27) 31617017

PROCESSO Nº 5002479-81.2021.8.08.0021

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868

SENTENÇA

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, partes qualificadas.

Aduz a impetrante, em síntese, que: i) a autoridade impetrada realizou interpretação equivocada das regras do inc. I do § 2º do art. 156 da CF/88 e dos arts. 36, I e II, e 37 do Código Tributário Nacional, ao afastar o reconhecimento da imunidade total do ITBI em razão de integralização de imóvel na constituição do capital social da empresa; ii) a autoridade impetrada reconheceu, somente em parte, a imunidade, até o valor de integralização do imóvel, de modo que, em razão de avaliação maior (valor venal) levada a efeito pelo Fisco Municipal, entendeu-se pela incidência do imposto sobre o valor da diferença apurada, o que deu ensejo ao apontamento, para recolhimento, do tributo no importe de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos); iii) o imóvel a que se refere a (não-) incidência tributária cuida-se do apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, que foi adquirido e constava da Declaração de Imposto de Renda dos seus então proprietários, casados em comunhão universal de bens, Fernando de Abreu Júdice e Ana Rita Marques Júdice, pelo valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); iv) o item "f" do parágrafo segundo da Cláusula 4ª do Contrato Social, que cuida do "CAPITAL SOCIAL E SUA INTEGRALIZAÇÃO", dispõe sobre o referido imóvel e aponta o referido valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para fins de sua incorporação; v) este valor, constante da declaração de bens do sócio Fernando Júdice prestada à Receita Federal do Brasil, não comportou atualização no momento da integralização nos exatos limites previstos e permitidos em lei, por opção do contribuinte, a fim de não ficar sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital; vi) esse foi o custo de aquisição para a pessoa jurídica, sendo que, na declaração de bens da pessoa física que o integralizou, o espaço destinado ao imóvel foi composto pelas quotas subscritas na mesma proporção (220 mil quotas referentes ao imóvel integralizado; vii) esta opção é legítima e prevista no art. 23 e parágrafos da Lei nº 9.249/1995; viii) o sócio Fernando de Abreu Júdice, por oportunidade da integralização, preferiu manter o valor do imóvel constante da sua respectiva declaração de bens, nos limites da lei, para efeito de não se submeter à incidência de imposto federal (IR sobre o ganho de capital); ix) houvesse atualização voluntária, incidiria, no máximo, sobre essa legítima operação, o imposto federal sobre eventual ganho de capital, mas jamais, uma vez integralizado o imóvel como realização de capital, o imposto municipal (ITBI) devido à regra constitucional imunizante; x) a opção legítima do sócio-contribuinte ao integralizar imóvel seu como realização de capital social de uma empresa da qual fará parte, sem atualizá-lo a valor presente de mercado, não pode ensejar a incidência de ITBI pela diferença a maior entre o valor integralizado e o valor venal proposto pelo município, por não ser esse o comando constitucional específico e, tampouco, o que restou decidido pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 796; xi) embora o inc. II do art. 156 da CF/88, em sua redação, preveja ser da competência dos Municípios a instituição de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, bem como de direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos a sua aquisição, o referido dispositivo constitucional, em seu § 2º, inc. I, traz uma regra imunizante ao afirmar que o ITBI "não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital", sem qualquer ressalva ou exceção, sendo o que ocorre no caso em exame com a integralização do imóvel pelo valor constante da declaração de bens (R\$ 220.000,00) e transformação em quotas proporcionais, ou seja, 220 mil quotas referentes ao respectivo imóvel; xii) a única exceção para a aplicação da regra imunizante que permite a incidência do tributo, reside na hipótese de a atividade preponderante da empresa adquirente, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, "for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de



bens imóveis ou arrendamento mercantil"; xiii) essa exceção à regra imunizante aplica-se somente à segunda parte do texto, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o que, também, não é a hipótese com a qual se depara; xiv) com isso, não foi recepcionado o art. 37 do CTN para a hipótese primeira constante da parte inicial da locução normativa: "não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"; xv) o art. 37 do CTN só tem, atualmente, aplicação para as hipóteses previstas na segunda locução da regra constitucional, que corresponde ao inc. II do art. 36, e, assim, a imunidade deixará de existir; xvi) essa moldura interpretativa ficou assentada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, em regime de Repercussão Geral (Tema 796); xvii) faz jus portanto à imunidade (não-incidência) total do ITBI quanto à integralização do imóvel pelo valor constante da declaração de bens e direitos do seu sócio, como parte do capital na constituição da pessoa jurídica; xviii) segundo decidido pelo STF, a imunidade somente alcança a operação de transferência de bens imóveis, em nome dos sócios, para a pessoa jurídica em realização de capital, caso o valor de tais bens não supere o do capital social declarado, de modo que apenas no caso de a importância que sobejou o capital social ser declarada como reserva de capital é que não estaria respaldada na regra imunizante; xix) assim, a imunidade deve ser absoluta quando, na integralização do capital da pessoa jurídica, o imóvel for vertido com todo o valor constante da declaração de bens dos sócios, e, assim, integralizado, sem reservas de valor à conta de reserva de capital ou de ágio; xx) o precedente do STF, do qual se vale o ato coator para justificar a exação, não autoriza, sob hipótese alguma, a cobrança sobre suposta diferença entre o valor do capital social e o valor da avaliação unilateral por parte do município, devendo haver o devido distinguishing.

Com base nestes fundamentos, pede a impetrante o deferimento de liminar para o fim de ordenar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00), em razão da imunidade tributária (não-incidência) prevista na primeira opção do inc. I do § 2º do art. 156 da CF/88 c/c o inc. I do art. 36 do CTN.

No mérito, pede seja reconhecido o direito líquido e certo de fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento no 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio, prevalecendo o valor constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 220.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresaria em 220 mil cotas, afastando, definitivamente e por completo, a exação de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra a ser apurada, ilegalmente, sobre a diferença entre o valor do imóvel acima destacado, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

A inicial foi instruída com documentos.

A decisão lançada no id. 8132556 indeferiu a liminar.

Os embargos de declaração apresentados no id. 8329640 foram rejeitados pela decisão registrada no id. 8349200.

As informações foram prestadas no id. 8543003.

O MPE entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no writ (id. 8576891).

No id. 8593747 a impetrante evidencia o depósito do valor integral do imposto e pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que foi acolhido na decisão lançada no id. 8603195, com fundamento no art. 151, II, do CTN.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, em síntese. Decido.

Almeja a impetrante o reconhecimento, em seu favor, da regra de imunidade tributária (não-incidência) prevista na primeira opção do inc. I do § 2º do art. 156 da CF/88 c/c o inc. I do art. 36 do CTN, relativamente ao ITBI, em operação



de integralização de imóvel pelo valor constante da declaração de bens e direitos do seu sócio, como parte do capital na constituição da pessoa jurídica.

Defende que a imunidade deve ser absoluta quando, na integralização do capital da pessoa jurídica, o imóvel for vertido com todo o valor constante da declaração de bens dos sócios, e, assim, integralizado, sem reservas de valor à conta de reserva de capital ou de ágio, conforme é possível extrair da interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, em regime de Repercussão Geral (Tema 796).

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 796.376 (Tema 796), em sede de repercussão geral, o STF decidiu que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

O caso concreto que ensejou o Recurso Extraordinário nº 796.376 (Tema 796) teve início com mandado de segurança impetrado por holding de participações de Santa Catarina contra ato do Secretário da Fazenda do município de São João Batista/SC. O contribuinte invocou a a imunidade do ITBI para integralizações de capital, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, que dispõe: "Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".

A Fazenda Municipal negou a imunidade ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor total dos bens sob a justificativa de que o valor dos imóveis excedia o capital integralizado. Assim, reconheceu a imunidade apenas com relação à parcela que efetivamente acresceu ao capital social da sociedade.

Naquele caso, restou apurado que o capital social foi integralizado mediante incorporação de imóveis com valor superior ao das cotas subscritas, sendo a diferença lançada, à conta de ágio, no patrimônio líquido. Ou seja, do valor atribuído aos bens na integralização, parte foi destinada ao aumento do capital social e parte à conta de reserva de ágio, aumentando o patrimônio da sociedade, mas não seu capital.

O que o município, na referida casuística, não aceitou, portanto, foi a imunidade sobre a parcela atribuída à reserva de ágio, reconhecendo a não incidência do ITBI apenas sobre a parcela do valor dos bens que efetivamente aumentara o capital da sociedade.

Ao apreciar o caso, o STF, através do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso, estabeleceu distinção entre os significados de "incorporação de bens em realização de capital" e "incorporação de bens ao patrimônio", expressões utilizadas, respectivamente, na primeira e na segunda oração do mesmo artigo 156, § 2º, I, da CF/88.

A primeira expressão refere-se a integralizações de capital em sentido estrito, enquanto a segunda diz respeito às operações de fusão, cisão e incorporação, em que há transferência de patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas não resultando em aumento de capital social.

Com base nessa distinção, foi afirmado que a hipótese de imunidade ao ITBI na qual os bens imóveis não crescem ao patrimônio seria apenas aquela citada no segundo trecho do referido dispositivo constitucional, consistente na fusão, cisão e incorporação, e que tais situações não se confundem com a imunidade para "incorporação de bens em realização de capital", em que, para fruição da imunidade, obrigatoriamente deve ocorrer integralização ao capital social. Ou seja, a imunidade, nessa hipótese específica, não pode alcançar a parcela do valor dos bens que não cresce ao capital, posto que isso revelaria interpretação extensiva, que não seria admitida por nosso ordenamento.

Assim, a primeira conclusão firmada pelo Excelso Pretório no precedente de caráter vinculante é a de que no caso de integralizações de capital, a diferença entre o valor dos bens imóveis que aumenta o capital social e a parcela do valor dos bens imóveis que é destinada à conta de reserva de ágio não é imune ao ITBI, devendo ser pago o imposto sobre a diferença, de modo que, quando todo o patrimônio imobiliário seja integralizado na conta de capital social, não há incidência do ITBI.



Mas não é só.

O voto vencedor, prosseguindo na distinção das imunidades para "realização de capital" (integralizações) e "incorporação de bens" (fusão, cisão ou incorporação), concluiu que a primeira hipótese de imunidade é incondicionada, enquanto na segunda a imunidade só é aplicável caso a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolva atividade preponderantemente imobiliária, conforme prevista no art. 37 do CTN. Senão vejamos:

"Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I — nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil' — revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão 'nesses casos' não alcança o 'outro caso' referido na primeira oração do inciso I, do §2º, do artigo 156 da CF.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do §2º, do artigo 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte.

(...)

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito".

Disso se depreende a segunda conclusão firmada pelo STF: as integralizações de bens imóveis ao capital de sociedades são imunes ao ITBI independentemente da atividade da empresa que recebe os imóveis, enquanto as transmissões de patrimônio imobiliário em decorrência de operações de fusão, cisão e incorporação estão condicionadas à ausência de atividade preponderantemente imobiliária da sociedade adquirente/incorporadora.

Estas são as duas conclusões adotadas pelo STF acerca do assunto, em sede de repercussão geral, consubstanciadas no Tema 796, valendo aqui ressaltar, como esclarecem Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, que "as razões de decidir do precedente é que operam a vinculação: extrai-se da ratio decidendi, por indução, uma regra geral que pode ser aplicada a outras situações semelhantes" (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 2, p. 460).

Logo, além de definir a nova tese de repercussão geral, o STF tratou também de esclarecer a questão da imunidade condicionada prevista no art. 156, que não guarda relação com a primeira parte do inciso I do § 2º, devendo, assim, as demais instâncias do Judiciário, em homenagem à estabilidade e coerência, observarem também a ratio decidendi do precedente.

Nesse ponto, muito embora o caso paradigma não tratasse da discussão acerca da atividade preponderantemente imobiliária, não há dúvidas de que o voto vencedor caminhou nesse sentido. Como se verifica, embora o objeto central do leading case fosse a incidência da imunidade em integralizações de capital na qual há excesso destinado a reserva de ágio, a ratio decidendi do precedente está toda calcada na distinção entre as duas hipóteses de imunidade previstas no artigo 156, § 2º, I, da CF, nas suas primeira e segunda orações.

O voto vencedor é enfático na distinção realizada para demonstrar que: i) a hipótese da imunidade relativa a integralizações é restritiva, estando prevista na primeira oração do dispositivo, não abarcando a parcela do valor dos imóveis que exceda o valor integralizado; e 2) a segunda hipótese, esta, sim, acoberta operações de incorporação de imóveis ao patrimônio de sociedades sem aumento de capital, mas estritamente em casos de fusão, cisão e incorporação. E, para esclarecer e reforçar tal distinção, o acórdão explica que esta última sim está sujeita à condição de atividade preponderantemente imobiliária, enquanto a primeira (integralizações) seria incondicionada.



Como se pode notar, esse argumento compõe a ratio decidendi do julgamento e, por tal razão, deve ser observada com efeito vinculante.

Aqui cabe o registro de que não houve discussão no referido leading case a respeito do "valor venal" dos imóveis, que consiste na base de cálculo do ITBI, e eventual diferença com relação ao valor atribuído aos bens para fins de realização de capital. A tese estabelecida pelo STF diz respeito à hipótese de integralização de capital em que ocorre a subscrição de ações ou quotas com ágio. Ou seja, a situação na qual o valor pelo qual o imóvel é transmitido à sociedade, parte é integralizada ao capital e parte é destinada à reserva de ágio.

Tanto o caso concreto que culminou no precedente em tela quanto sua ratio decidendi limitam-se a essas situações, não havendo consideração ou decisão a respeito de possível diferença entre o valor venal (valor de mercado) e o valor pelo qual os bens são transmitidos, que, em regra, por autorização legal, consiste no seu custo contábil justamente por isenção tributária prevista na legislação federal do imposto de renda (Lei nº 9.249/95, art. 23).

Fica evidente, então, que o Supremo Tribunal Federal jamais firmou a tese de que a imunidade de ITBI não abrange a diferença entre valor de incorporação e valor de mercado (ou valor venal, atualizado etc), especialmente quando todo o montante se destina à realização de capital aludida no art. 156, § 2º, inc. I, da CF/88, sem ágio/formação de reserva de capital.

Dessarte, não se pode dizer, como pretende a autoridade impetrada, que a tese firmada através do Tema 796, de repercussão geral, se aplica aos casos em que a totalidade do valor de incorporação imobiliária é destinada à realização de capital social, sem a formação de reserva de capital, mesmo que o imóvel apresente diferença entre valor de incorporação e de mercado.

Mostra oportuno lembrar que o Código Civil, ao tratar sobre o direito empresarial, fixa as regras gerais sobre a constituição de sociedades limitadas e faculta, no inc. III do art. 997, cumulado com o art. 1.054, que o capital social da empresa compreenda "qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária". Por este motivo, aqueles que pretendem constituir uma sociedade limitada podem escolher os bens que, em troca da participação societária a ser adquirida, transferirão para a pessoa jurídica a título de integralização de capital social.

Quando se opta por integralizar capital social através de bens imóveis, tem-se uma transmissão de propriedade imobiliária que, não fosse o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, constituiria fato gerador de ITBI, conforme previsão do inc. II do art. 35 do Código Tributário Nacional. Nesta hipótese, tem-se que os bens imóveis utilizados para fins de integralização deixam de compor o patrimônio do respectivo sócio, que, em contraprestação, passa a ter quotas da sociedade em quantidade correspondente ao valor da incorporação imobiliária.

Esta operação, imune de ITBI, causa relevantes efeitos fiscais, sendo o principal deles relativo à Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do sócio que está realizando a integralização, na qual deixará de constar determinado bem imóvel e passará a constar quotas da empresa cujo capital social recebeu a propriedade imobiliária.

Ocorre que quando a integralização não é feita em dinheiro, cabe aos sócios estimar o valor dos bens conferidos ao capital social, conforme prevê o § 1º do art. 1.055 do Código Civil. A própria doutrina ensina que: "Se a integralização é feita pela conferência de bens, os sócios lhes atribuirão um valor estimado, não havendo a exigência da apresentação de laudo de avaliação, como ocorre na sociedade anônima (art. 8º da Lei n. 6.404/76)" (CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de empresa (artigos 1.052 a 1.195). Vol. 13. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. E-book).

Neste sentido, a Lei 9.249/95, nos §§ 1º e 2º do art. 23, dispõe sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, a saber, pelo valor histórico (constante na DIRPF) ou por montante superior a ele:

"Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º - Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão



lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º - Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital."

Como se nota, pelo regramento alhures recordado, trata-se de faculdade do sócio integralizar o imóvel pelo valor constante da declaração ou pelo valor de mercado. Logo, há autorização legal para que o contribuinte integralize bens imóveis pelo valor de mercado ou pelo valor constante na DIR. É uma opção do contribuinte legalmente permitida.

Em assim sendo, o fato de o sócio dar em pagamento do capital social um imóvel, pelo valor constante em sua declaração de imposto de renda, nos termos como permite a legislação federal, conduz à conclusão de que todo aquele imóvel, independentemente de seu valor atual de mercado, foi dado em pagamento, não restando valores a serem incorporados à sociedade para reserva de capital (esta sim, não incluída na regra imunizante).

A regra constitucional não trouxe limitação relacionada a valor, se o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado é menor que o valor declarado; a única limitação, relacionada à segunda hipótese imunizada ("transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica"), liga-se à atividade preponderante. Desse modo, não se pode limitar uma imunidade quando a própria Carta Magna não o fez.

Se o imóvel é dado como subscrição de capital social e integralizado como tal, a imunidade deve incidir. Diferente é o caso de parte do imóvel ser dada em pagamento pelo capital social (imune à incidência do ITBI) e outra parte do mesmo imóvel, especificando-se os valores relativos a cada uma, é acrescentada à sociedade para outros fins que não a integralização deste capital. E esta foi a ratio decidendi do STF no RE 796.376.

Assim, em relevo à referida normatização, o valor disposto na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do sócio, quando adotado referido critério para a integralização, é que deve servir como parâmetro para se realizar o cotejo com o valor do capital social, visto que o diferimento, concedido pela União aos contribuintes que não desejam recolher o ganho de capital no momento da integralização, não pode ser tolhido pelos municípios.

Nessa esteira, a interpretação desenvolvida pela autoridade impetrada, a qual vêm sendo adotada por outros municípios, no sentido de que, independentemente da existência de ágio na subscrição, sempre que o valor venal for superior ao valor atribuído ao imóvel para fins de integralização, a diferença estará sujeita à incidência de ITBI, não encontra fundamento de validade no enfatizado precedente do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que: i) a imunidade constitucional abrange os imóveis transmitidos a título de realização de capital; ii) o STF entendeu que a incidência ou não do ITBI nas integralizações deve identificar se, do valor pelo qual o imóvel é transmitido à sociedade, parte dele é destinada a reserva de ágio, esta sim sujeita ao ITBI; iii) na situação em análise há exata correspondência entre o valor pelo qual o imóvel foi transmitido à sociedade e o capital social integralizado, não havendo reserva de ágio; e, por fim, iv) a legislação tributária expressamente autoriza a transmissão do imóvel pelo valor de custo/declarado.

No caso em exame, está evidenciado nos autos que não houve por ocasião da integralização do imóvel qualquer registro de parte do valor do imóvel à conta de reserva de capital ou de ágio, representando o valor declarado justamente o valor das cotas subscritas pelo sócio, não havendo, assim, excesso ao limite do capital social integralizado, e, portanto, formação de excedente ou reserva de capital que autorize a incidência do ITBI sobre eventual diferença, conforme escorreita interpretação a ser conferida ao Tema 796 firmado pelo STF (TJSP - AC: 10027585220188260438 SP 1002758-52.2018.8.26.0438, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 07/01/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/01/2021).

Ademais, embora a hipótese de imunidade versada nos autos seja incondicionada ("transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"), conforme a fundamentação supra, mostra-se oportuno consignar que não há nos autos qualquer indicativo de que a atividade preponderante da impetrante seja uma daquelas que encontra vedação no dispositivo constitucional para incidência da imunidade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no



artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

Custas ex lege pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Sem condenação em honorários, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/09 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário (Lei nº 12.016, art. 14, § 1º).

Com o trânsito o julgado, deverá ser levantada a caução depositada com vinculação aos autos, mediante sua restituição à impetrante.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I.

GUARAPARI-ES, 20 de outubro de 2021.

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

Juiz de Direito



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

Alameda João Vieira Simões, 135, Fórum Desembargador Gregório Magno, Muquiçaba, GUARAPARI - ES - CEP: 29214-110
Telefone: (27) 31617017

PROCESSO Nº 5002479-81.2021.8.08.0021

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868

SENTENÇA

(embargos de declaração)

Cuida-se no id. 10252840 de embargos de declaração opostos pela impetrante, nos quais aponta suposta omissão da sentença no que concerne à apreciação do pedido formulado na letra "b" do tópico VIII.2, qual seja: "também, no mérito, seja definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN. uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF ('transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital')".

Ao que se denota do dispositivo da sentença embargada houve a concessão da segurança, no caso concreto apresentado, "para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 43.799, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 200.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 220 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00).

Nessa esteira, restou plenamente atendida a pretensão apresentada na inicial, decorrendo da fundamentação que integra e delimita o alcance do dispositivo os apontamentos de que a hipótese de imunidade apreciada é incondicionada, e de que não há nos autos qualquer indicativo de que a atividade preponderante da impetrante seja uma daquelas que encontra vedação no dispositivo constitucional para incidência da imunidade.

Não há necessidade, assim, e disto não decorre omissão, de emissão de uma declaração apartada acerca da não submissão da imunidade que foi reconhecida no dispositivo da sentença às limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, porque incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

Importa ponderar que não constitui o MS via adequada para estabelecimento de teses abstratas, via tutela declaratória, quando inexistir utilidade ou referibilidade concreta, conforme se verifica na espécie, em que restou reconhecida a imunidade em operação específica, o que constitui e exaure o objeto do writ.

À luz do exposto, porque desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes NEGO PROVIMENTO.

P. R. I.

GUARAPARI-ES, 10 de novembro de 2021.

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA



Juiz de Direito

